

Ésta costumbre fue practicada también por particulares y es con las casas edificadas, superficiarias *aedes*, que el pretor sancionó en beneficio del superficiario un derecho real: el derecho de superficie.

El derecho civil consideraba que el locatario del terreno de otro, no es propietario del edificio que él ha construido, porque el propietario del terreno tiene la propiedad de la superficie, es decir de las edificaciones construidas sobre el terreno.

Éste derecho de superficie consagrado por el derecho pretoriano, implicaba una excepción a ese principio general.

El pretor concedió al superficiario, para mantenerlo en la posesión, el interdicto de superficie.

También en caso de locación a perpetuidad o a largo plazo, el pretor podía otorgarle:

- a) Una *actio in rem* para hacer valer su derecho contra todos, aún contra el propietario.
- b) Una *exceptio* contra la *reivindicatio* del propietario.

A partir de entonces, el superficiario tuvo un derecho real que podía enajenar inter vivos, hipotecar y transmitir a sus herederos. La superficie se constituía por un contrato y la cuasi tradición y se extinguía por la pérdida de la cosa y por la llegada del término fijado para su duración.

II. Derechos reales de garantía

Las seguridades o garantías reales que existieron antes que la prenda y la hipoteca fueron la venta que se hacía bajo pacto de fiducia, cuando se hacía la venta fiduciaria de una cosa al acreedor y debía transferir la propiedad de la cosa al deudor cuando quedaba liberado de la deuda.

La Prenda

Cuando el deudor contraía una obligación, el acreedor buscaba una forma de garantizarse su pago, lo hacía a través del *pignus* o pren-

da. El acreedor tenía la posesión y el deudor la propiedad, en caso de que el acreedor no se la restituye podía pedirlo por medio de una *reivindicatio*.

Encuentra su antecedente en la Ley de las XII Tablas, cuando se dispuso que la toma de prenda se estableció por ley contra aquel que hubiera comprado un animal para sacrificarlo a los dioses y no pagara el precio; de igual manera contra el que no entregase el alquiler de una caballería siempre que el dinero de tal alquiler se hubiera destinado para realizar una ofrenda. Eran situaciones especiales y taxativas contempladas en el sistema primitivo de las *Legis Actionis*, más precisamente en la *legisactionem per sacramentum*.

Al principio fue un derecho de retención ejercido por el acreedor y con el paso del tiempo se le autorizó al deudor a vender la cosa y descontar de allí lo adeudado.

Las garantías podían ser reales o personales:

- 1) Personales: Son aquellas por las cuales una o más personas se obligan hacia el acreedor junto con el deudor principal, de manera que aquél pueda dirigirse a personas solventes, si éste no lo es. Por ejemplo: la fianza.
- 2) Reales: Son aquellas por las cuales se afecta una cosa al pago de una deuda (hipoteca, prenda, anticresis, etc).

Las garantías personales se establecieron antes que las reales, debido a que era frecuente que las personas dieran fe de las operaciones de los clientes. En Roma no había un solo fiador sino varios, una serie de leyes debilitaron las fianzas, creando las seguridades reales. Estas leyes fueron:

- 1) La ley *Publilia*: Se le permitía al fiador que había pagado imponer la *manusiniectio* sobre el deudor al que le había pagado la deuda.
- 2) La ley *Apuleia*: Establecía una especie de asociación entre los fiadores. Si el primero paga tiene derecho a repetir sobre los otros tres su parte viril, e acreedor se dirige a uno solo de los fiadores y ellos se arreglan entre sí.

- 3) *La ley Furia*: Era una simplificación de la anterior, obligaba al acreedor a dividir entre los fiadores el importe de la deuda.
- 4) *La ley Cicereia*, a veces ocurría que el fiador no hacía público el número de sus fiadores o uno de éstos podía ser insolvente. Ésta ley obligó a declarar el número de fiadores, al acreedor.

De ésta manera se va debilitando la fianza y aparecen las garantías reales, pero la hipoteca es creación del pretor y antes que ésta existieron otras formas de garantizar el pago.

Existió la enajenación como fiducia; el deudor transfería al acreedor por emancipación *in iure cessio*, la propiedad de una cosa que forma parte de su patrimonio, agregándose un pacto de fiducia, por el cual el acreedor se compromete a devolver la propiedad de la cosa al deudor después del pago, dándoselo a éste con el fin de obligarlo la *actio fiduciae* directa y la podía recobrarla por la *usureceptio*.

En el supuesto de que el deudor no pagara, la *usureceptio* no era posible y el acreedor puede vender la cosa, obteniendo un precio superior, debiendo entregar el excedente al deudor.

Debido a los inconvenientes que presentaba, el derecho civil admitió una forma más simple sobre todo para el deudor, era el contrato de prenda o *pignus*. El deudor entregaba al acreedor a título de prenda la posesión de una cosa y el acreedor se obligaba a devolverla una vez que se hubiera pagado. El acreedor pignoraticio tenía la simple tenencia y las ventajas de la posesión se reparten entre él y el deudor.

La enajenación con fiducia como el *pignus* agotaban en ese primer acto el crédito del deudor, que se desprendía de la cosa, se dejaba librado a la buena fe del acreedor, además solo contaba para defender su *pignus*, los interdictos. Los problemas se presentaban entre el colono y el arrendador de un fundo rural, con el fin de garantizar al propietario, el colono que no tenía más que el ganado y los instrumentos destinados al cultivo del suelo no podía cederles su propiedad o posesión, porque se quedaba sin sus instrumentos laborales. Por eso con el paso del tiempo se estableció que los objetos mencio-

nados, el colono lo utilizara como forma de garantizar el pago del arrendamiento por simple acuerdo, sin que se lo privara al colono de sus elementos de trabajo.

La hipoteca

La hipoteca, aparece primero en las relaciones entre el propietario de un fundo y el colono, éste conserva la propiedad y la posesión de la cosa y se establece por un pacto que el acreedor tiene derecho de retención sobre la cosa cuando el deudor no cumple con su prestación.

Ésta forma de garantía no era suficiente por eso con el paso del tiempo el Pretor *Salviano* otorga el interdicto que lleva su nombre: el interdicto *Salviano*.

Se podía entregar como garantía los esclavos y otros elementos necesarios para el cultivo introducidos por el arrendatario (locatario) en el fundo arrendado fueran dados en prenda para garantizar el pago del alquiler (locación); el pretor con su labor jurídica protegió esa garantía por la labor del pretor *Salviano* con el interdicto *Salviano* para darle al locador la posesión de esos bienes mientras estuvieren en el fundo arrendado, siempre y cuando hubiese incumplimiento; pero también se podía encontrar con el inconveniente de que el deudor había transferido la cosa a un tercero, entonces aparece la *acción serviana* para reclamar la posesión de los bienes que había ido a parar a manos de quién esté, se trataba de una acción in rem. Tanto el interdicto como la acción tenían un campo de acción reducido y se trató de extender su aplicación.

Fue así que nació la acción *serviana útil o quasi serviana* o hipotecaria a todos los acreedores que habían celebrado convenio con sus deudores, por la que se afectaban determinados bienes como forma de garantizar el pago, pero sin perder la posesión de ellos; se llamó hipoteca, tenía la misma misión que el *pignus* pero no requería la transmisión de la cosa al acreedor. La hipoteca aparece como una garantía más eficaz, ya que el acreedor hipotecario era pagado con preferencia a otro acreedor que hubiese constituido su derecho a posteriori.

Caracteres de la hipoteca

- 1) Derecho real accesorio: Porque siempre supone la existencia de una obligación, cuyo cumplimiento va a garantizar, se podía referir también a una deuda futura.
- 2) Derecho indivisible: La indivisibilidad se funda en la voluntad presunta de las partes. La hipoteca subsiste íntegramente cuando parte de la deuda hubiera sido pagada.

Objetos sobre los cuales podía recaer la hipoteca

- a) Podía recaer sobre las cosas *in commercium*.
- b) Cosas muebles e inmuebles.
- c) La cosa dada en usufructo.
- d) El acreedor hipotecario podía hipotecar su propia hipoteca.
- e) Se podía hipotecar un crédito.
- f) También había hipotecas generales, eran las que recaían sobre todo el patrimonio.
- g) Se extendió también sobre los bienes que afectaba un derecho real, por ejemplo, los intereses.

Constitución de las hipotecas

Podía ser:

- 1) Convencional: La hipotecase podía crear por acuerdo entre las partes.
- 2) Testamentaria: Ocurría cuando el testador quería dar una garantía a un legatario de renta vitalicia o de alimentos.
- 3) Tácita: Se establecía de esta manera cuando había sido creada por ley. Dentro de éstas encontrábamos:
 - a) La del arrendador de un fundo rural sobre los frutos del inmueble.
 - b) La del arrendador de una cosa sobre las cosas introducidas por ella por el arrendatario.

Otras gravaban todos los bienes del deudor siendo las principales:

- a) La hipoteca tácita del fisco sobre los bienes de los deudores.
- b) La que otorgó Constantino a favor de los pupilos y menores de 25 años, sobre los bienes de tutores y curadores.
- c) Justiniano favoreció a la mujer casada y a sus hijos, con una hipoteca tácita sobre los bienes del marido para garantizar la restitución de la dote, después de la disolución del matrimonio.

La constitución de la hipoteca podía ser realizada no solo por el propio deudor, sino también por un tercero que afectaba su cosa, pero siempre que fuera propietario de ella, o al menos que la tenga *in bonis* y que tuviera capacidad para enajenarla.

Extinción de la hipoteca

La hipoteca era accesoria al crédito que acompañaba. Por lo tanto extinguida la deuda se extinguía la garantía. Aunque también se podía extinguir por:

- a) Pérdida de la cosa hipotecada.
- b) Confusión: la cosa hipotecada era adquirida por el acreedor hipotecario.
- c) Renuncia del acreedor. Podía ser expresa o tácita.
- d) Prescripción extintiva. A los cuarenta años, en relación al deudor.
- e) *Praescriptio longi temporis*: Respecto del tercero poseedor.

Efectos de la hipoteca

El *ius possidendi*. El *ius distrahendi pignus*.

Al principio le daba la hipoteca al acreedor el derecho de requerir la posesión de la cosa, al no pagársele, conservándola hasta recibir la satisfacción de su crédito. Como ello no daba el resultado esperado se buscaron soluciones más rápidas.

Así las partes celebraban el pacto *commisorio*, por el cual el acreedor que no había pagado se convertía en propietario de la cosa, el

problema que se planteaba era cuando el deudor entregaba en *pignus* una cosa que tenía un valor superior al de la deuda y fue finalmente Constantino quién la prohibió.

Las partes podían celebrar que la hipoteca era la que autorizaba al acreedor a vender las cosas en caso de que el deudor no pagase. Con el paso del tiempo se hizo una práctica habitual, la venta podía ser una consecuencia de la falta de pago, en tiempos de Justiniano esa era la esencia de la hipoteca, el acreedor solo tenía que esperar dos años antes de vender la cosa.

El acreedor hipotecario tenía los siguientes derechos:

- a) De ir contra cualquier detentador de la cosa por la acción real hipotecaria (*quasi serviana*) para empezar a poseerla (*ius possidendi*).
- b) De vender la cosa hipotecada (*ius distrahendi pignus*).
- c) De cobrarse con el precio con preferencia a los demás acreedores sin garantía real.
- d) Se podía ir contra el deudor y contra el tenedor, aunque éste podía oponer:
 - 1) Se tenía sobre la misma cosa una hipoteca preferente a la del actor.
 - 2) Podía obligar al acreedor, pagándole la deuda, a cederle sus acciones (*beneficium condendarum actionum*).
 - 3) El beneficio de excusión le permitía al tercer poseedor, exigirle al acreedor que se dirigiera primero contra el deudor principal y contra las cauciones, mediante la acción personal.
- e) Derecho de venta: Las cuestiones de cómo procedía la venta si las partes nada habían acordado, las reguló Justiniano, el acreedor tenía que intimar al deudor, o sino obtener un sentencia contra él y esperar dos años para proceder a la venta. En el caso que hay una cláusula prohibiendo la venta, el único efecto que se le atribuye era que se requieren tres intimaciones en vez de una.

En el caso que el acreedor no encontrara comprador, se po-

día adjudicar el bien por decisión de Emperador, mediante un precio que se fijaba por estimación judicial. El deudor podía recuperar la cosa antes de los dos años pagando el capital, los intereses y los daños y perjuicios. Al vender la cosa el acreedor hipotecario transfiere su propiedad al comprador, actuando como un mandatario del deudor.

Derecho de preferencia

Realizada la venta el acreedor tenía derecho a cobrarse sobre el precio, con preferencia a todos los otros acreedores, pues la cosa vendida estaba afectada especialmente a ese crédito. Si el precio que se obtenía no cubría el crédito, subsistía una acción personal sobre el resto, la cuestión se planteaba cuando había pluralidad de hipotecas.

Multiplicidad de hipotecas

Se aplicaba la regla, “primero en el tiempo mejor en el derecho”, significaba que el primer acreedor que constituía la garantía al pago de la deuda sobre la cosa, el primero en ser tenido en cuenta cuando se le debía pagar en caso de ser ejecutada la cosa, seguían luego los sucesivos constituyentes de la garantía. El primer acreedor gozaba del *ius possidendi* y del *ius distrahendi*, aún frente a los demás acreedores que le seguían en orden. El primero podía perjudicar, sin proponérselo el derecho a cobrar de los demás, el comprador adquiría la cosa libre de gravámenes.

A los demás acreedores les quedaba la posibilidad de cobrarse sobre el excedente que hubiese quedado del precio de la venta, una vez que se hubiese pagado al primer acreedor. La eficacia de la garantía desaparecía para éstas personas, un defecto que se veía agravado por:

- 1) La clandestinidad de la hipoteca.
- 2) La existencia de hipotecas tácitas.

La publicidad de la hipoteca era deficiente y los terceros no eran advertidos de la existencia de una primera hipoteca, en cuyo conocimiento no hubieran tratado con el deudor. La situación fue atenuada

por distintos medios:

- a) El que hipotecaba enajenaba una cosa debía declarar si ya estaba gravada con una hipoteca, si no lo hacía cometía el delito de estelionato y se exponía a una acción criminal.

Los acreedores posteriores tenían el *ius offerendae* pecunia. Era el derecho del acreedor hipotecario de tomar el lugar de uno anterior, a quién se desinteresaba abonándole su crédito (*successio locum*), no adquiría la hipoteca del primer acreedor sino que la suya pasaba a ocupar el primer rango, en raras ocasiones el acreedor hacía uso de ese derecho para desinteresar a otro posterior, cuando por ejemplo, él no tuviera pacto de venta y los demás acreedores sí.

Una constitución de León, le dio preferencia a las hipotecas que constaran en instrumentos públicos o privados, firmados por tres o más testigos.

Hipotecas privilegiadas

Como se dijo anteriormente, se privilegia la constitución de la garantía en el tiempo. Sin embargo excepcionalmente se establecían hipotecas privilegiadas establecidas por la ley, por la naturaleza del crédito que garantizaban, eran primarias a las demás, aunque ella fuera posterior.

Las principales hipotecas tácitas fueron:

- a) La del que ha invertido dinero en la adquisición o mejora de una cosa hipotecada, porque se considera que ese dinero ha salvado la existencia de la prenda.
- b) La de la mujer sobre los bienes del marido, para asegurar la restitución de la dote. Justiniano estableció que aún primaba sobre los anteriores a la celebración del matrimonio.
- c) La hipoteca del fisco sobre los bienes de los que adeudaban impuestos.
- d) Constantino concedió una hipoteca tácita a los pupilos, sobre los bienes de sus tutores y curadores

Derechos personales: Las obligaciones

Las Obligaciones

Antecedentes:

Fueron también llamadas derechos personales, en oposición a los derechos reales.

Encuentran su origen en las deudas contraídas por aquellos que, una vez vencido el plazo de cumplimiento de la obligación no podían hacer frente a la misma. Era entonces, cuando el acreedor lo encadenaba, la cadena era la *vincula*, lo que los unía físicamente.

Con el paso del tiempo dejó de ser la atadura física para pasar a ser jurídica. De ésta manera la *vincula*, pasó a llamarse *nexum*, ara una atadura ala creedor pero no física, sino jurídica.

Concepto

Las obligaciones o derechos personales era un vínculo de carácter jurídico – *vinculum iuris*- establecido entre dos personas: el deudor y el acreedor, para forzar, constreñir, para hacer o no hacer algo a favor

de otro; existiendo a la vez en el vínculo un valor pecuniario. Era una sujeción de carácter voluntario.

Encuentran si origen en las normas jurídicas romanas que las pre-establecían como: los delitos y los contratos, la primigenia clasificación Gayana: después se hizo extensivo a las varias figuras de causa por el Emperador Justiniano.

La *Lex Poetelia Papiria*

En la evolución del *nexum*, ese vínculo existente entre el deudor y el acreedor a partir del momento que nacía la *obligatio*, tuvo una primera fase que coincide con la etapa de formación de Roma y de las instituciones jurídicas. Era la época más primitiva, en que el derecho se fue construyendo en base al fas o elemento religioso. El fas determinaba el cumplimiento de las formas o solemnidades y cuando el deudor insolvente confesaba su situación o era condenado en un proceso judicial, se aplicaba la *manus iniectio* sobre él. Era una forma que tenía el acreedor de garantizarse la obtención de lo debido. Hubo una época que, como consecuencia de los préstamos dinerarios eran desmedidos los préstamos dinerarios a ellos se sumaban los intereses usureros, que existían a pesar de estar prohibida la usura.

Los deudores no podían hacer frente a las devoluciones de los préstamos y por ese motivo eran ejecutados con las restricciones a la libertad ambulatoria por parte de los acreedores. La situación fue intolerante hasta que los *nexii* deciden rebelarse, ese fue el origen de la sanción de la *Lex Poetelia Papiria* en el año 326 a. C. aproximadamente. Se decidió a partir de ésta *lex* que las ejecuciones no fueran sobre la libertad de los endeudados sino sobre su patrimonio.

Clases de obligaciones

División según el objeto

a) Según el vínculo: Eran vistas desde el punto de vista de la mayor o menor eficacia del vínculo. Podían ser:

- 1) Obligaciones del derecho civil y del derecho de gentes. Las primeras son las que derivan de los contratos del derecho

quiritario como el *nexum*. Mientras que los segundos, se llevaba a cabo entre ciudadanos romanos, eran formales y estaban protegidos por el derecho civil. Proviene del *iusgentium* como la compra-venta, locación, comodato, depósito, por mencionar algunas, la mayoría pertenecían a ésta última. No era necesario en éste último caso el uso de las formalidades, servían para llevarlas a cabo con, los extranjeros por eso se facilitó su uso.

- 2) Obligaciones civiles y honorarias: Las primeras son las que provienen de las leyes en general, pueden ser de los senadoconsultos y constituciones imperiales por ejemplo. Las segundas provienen de la norma jurídica dictada por el pretor, en el ejercicio del *iusedicendi*. Están protegidas por una acción. Eran perpetuas. Las segundas, son creaciones del Pretor cuando dictaba normas con el fin de suplir, corregir o llenar vacío del derecho en los casos que se les requiriera. También había normas de otros magistrados como el edil o el prefecto del Pretorio. Prescribían al año, era el plazo de vigencia del edicto. Igualmente las distinciones siguieron existiendo aún en vigencia del Edicto Perpetuo de Salvio Juliano. La diferencia desapareció con la sanción de una constitución del Teodosio II y Honorio, al disponer la prescripción treintañal para toda clase de obligaciones. Sin embargo el Pretor la aplicó en los casos que no estaba contemplado en la ley por ejemplo cuando se hizo extensiva a la responsabilidad del armador del buque por aquellas obligaciones contraídas por el capitán cuando se las había a encargado e éste por negocios entre ambos. (acción *exercitoria*).
- 3) Obligaciones de derecho estricto y de buena fe: Las primeras tenían su origen en el derecho quiritario, caracterizado por el rigor formal de la etapa primitiva del derecho, frente a la pronunciación de las palabras solemnes ante el

magistrado éstas debían cumplirse al pie de la letra como si fuera la ley misma. Derivaban de los contratos unilaterales como el *nexum*, la *stipulatio* o el contrato *litteris*, mientras que los *bonaefidei* procedían de los sinalagmáticos, ya sean perfectos o imperfectos. Estaban protegidas por las acciones *stricti iuris*, cuando se establecía el monto de la pena en la *condemantio*, cuando quedaban probados los hechos aducidos por el actor no podía hacer modificaciones a ese monto, esa *condemnatio* debía aplicarse estrictamente. En la acción *stricti iuris*, lo único que el *iudex* debía tener en cuenta es si había una deuda y cuál era su monto. El acto del que derivaba solo obligaba a una de las partes. La acción *bonaefidei* derivaba de un contrato sinalagmático se tenían en cuenta por parte del juez diversas situaciones, por ejemplo el derecho que invoca el depositario a que se le restituyan los gastos realizados. De esta manera aplicándose la buena fe y la equidad el juez analizaba éstas situaciones que surgían del contrato. No se podía invocar dolo o violencia además de otros vicios del consentimiento porque solo se trataba de determinar la existencia del crédito y su monto. En las obligaciones de buena fe, sí podían invocarse cuando el obligado oponía excepciones. En caso de haber mora los efectos de ésta alcanzaban a las obligaciones de buena fe, en cambio si eran de derecho estricto aún en mora no había obligación de pagar los intereses o devolver los frutos de la cosa adeudada. Las de derecho estricto no podían compensarse, las de buena fe: sí.

- 4) Obligaciones naturales: Tiene dos aspectos, por un lado aparecen para contraponerlas a las civiles. Por otro lado, se refiere a aquellas obligaciones que no están dotadas de una *actio*, por ejemplo las obligaciones que emergen de los actos negociales celebrados de los esclavos que care-

cen de capacidad jurídica. El vínculo jurídico es fuerte a diferencia de lo que ocurre en las obligaciones civiles. El cumplimiento depende del deudor, pero una vez realizado no había acción de repetición, ni siquiera podía invocar la *condictio indebiti*, cuando pagó por error creyéndose civilmente obligado al pago. Podía ser objeto de compensación y de novación. Podía ser garantizada con una hipoteca.

b) Obligaciones según la naturaleza de la prestación

- 1) *Dare*: Es la entrega material de la cosa, siempre y cuando exista un título jurídico que lo avale. Por ejemplo: cuando el comprador recibe del vendedor la cosa por la cual pagó un precio cierto en dinero, la transferencia de la cosa implica a la vez la transmisión del derecho de propiedad. Otro caso sería el del heredero respecto del acervo recibido del *de cuius*.
- 2) *Praestare*: La entrega material de la cosa no implica transferencia del dominio, pero sí de otro derecho real, por ejemplo la *possessio* en el caso del locador de la cosa respecto del locatario, mientras dure el contrato.
- 3) *Facere*: El objeto de la *obligatio* puede consistir en un hacer, en una acción o conducta de carácter positivo. Por ejemplo: el cuadro que se le encomienda realizar al artista plástico, respecto del cual recibirá una remuneración, siendo un caso claro de locación de obra. De ésta se desprende la obligación *non facere*, que, por el contrario exige una abstención de quién tiene la obligación de omitir la realización de ciertas conductas; por ejemplo: por imposición de la Ley de las XII Tablas respecto de aquél que no puede levantar un muro que exceda una cierta altura, ya que puede perjudicar las luces o vistas del vecino.

c) Determinación en indeterminación de la prestación: En el primer caso se refiere, a que el objeto tiene que estar individualizado, como regla general desde el comienzo de las obligaciones, en ese caso la

prestación es determinada, por ejemplo: un esclavo X, se llama prestación de especie (asimilado a la noción de individuo). Por pérdida fortuita de la cosa el deudor queda liberado, no se puede substituir por otro. Algo similar ocurre si el esclavo muere sin que intervenga la culpa del deudor.

En cuanto a las obligaciones indeterminadas, estas pueden ser:

- Genéricas o de género: Se va a entregar una cosa que está determinada por sus características o cualidades que la hace similar a otras, y por lo tanto son sustituibles. Por ejemplo; el trigo, un esclavo (sin dar su nombre de pila). Lo genérico permite ampliar el margen al momento de cumplir con la entrega del objeto, por ejemplo si se prometió un esclavo, no importa si es más bajo o más alto. El objeto será indeterminado hasta que opere su efectivo cumplimiento. Como regla general la elección de la cosa a entregar estará a cargo del deudor, en otros casos por ejemplo en los legados, la materia corresponde al acreedor o sea el heredero sobre el que pesa la carga de entregar la cosa legada al legatario. La elección la tiene el acreedor en otros casos cuando hubiera sido acordado por las partes.

Dentro de ésta clase de obligaciones encontramos las siguientes:

- Obligaciones de dar cosas fungibles: Sin fungibles aquellas cosas que pueden ser reemplazadas por otras de igual calidad, peso o cantidad (obligaciones de dar cantidades de cosas). Se puede cumplir por partes si hay pluralidad de sujetos activos o pasivos. Se aplica la regla “el género nunca perece” por ese motivo no hay excusa para incumplir, se debe entrega el objeto aún cuando el anterior pereció por caso fortuito.
- Obligaciones de dar cantidades: Son de carácter especial las de dar sumas de dinero. Se tiene en cuenta el dinero vigente al momento de hacer entrega del mismo, en caso de haber cambiado la moneda desde que se contrajo la *obligatio*.

- Obligaciones alternativas y facultativas: En las primeras hay una indeterminación inicial, tiene por objeto una entre varias prestaciones independientes entre sí, queda individualizada al momento de cumplir con la prestación. El acreedor entre varias prestaciones, solo puede exigir una de ellas. Son indivisibles: no puede cumplirse por partes esa prestación.

Son aquéllas que tienen un objeto que es indicado con la disyunción “o” por ejemplo. El esclavo “o” el caballo, pero al momento de cumplir con la prestación solo deberá entregarse uno solo, nos son dos objetos, solo se debe uno. Por lo tanto son: compuestas, indeterminadas hasta que se defina el objeto, e indivisibles. La elección de la prestación le corresponde al deudor salvo acuerdo en contrario. La elección puede ser a cargo del acreedor cuando hace la *interpellatio*, el deudor está en mora y le exige el cumplimiento, aunque hubo una discusión doctrinaria al respecto, ya que el deudor podía cambiar de objeto hasta el momento del efectivo cumplimiento.

-Si una de las prestaciones no puede cumplirse por caso fortuito, la elección se vuelve pura y simple con el objeto subsistente.

-Si se perdió por culpa del deudor y la elección estaba a cargo de él, cumple entregando la subsistente. Si la elección era del acreedor éste puede exigir el valor estimado del objeto que pereció o el objeto subsistente.

-Si la prestación se vuelve imposible de cumplir por culpa del acreedor el deudor queda liberado. Otros consideran que puede pedir una indemnización por la que se perdió y entregar la subsistente. Se aplican las disposiciones de la *Lex Aquilia* sobre daño injustamente causado sobre cosa ajena.

En el caso que se vuelvan imposibles de cumplir todos os objetos, se aplican las siguientes reglas:

-si fuera por caso fortuito el deudor queda liberado.

-Si fuera por culpa del deudor, debe el valor del último objeto extinguido, salvo que la elección sea del acreedor deberá darle el valor equivalente del objeto elegido.

- Si la primera fuera imposible por caso fortuito y la última por culpa del deudor, debe el doble del valor de la última.
- Si la primera se extingue por culpa del deudor, se convierte en obligación pura y simple y debe la segunda, si ésta se extingue por caso fortuito el deudor queda liberado.
- Si la primera se extingue por caso fortuito y la segunda por culpa del acreedor, el deudor queda liberado.

Las obligaciones facultativas

Son aquéllas en las que el deudor se obliga a cumplir con una prestación determinada, pero reserva para sí la facultad de liberarse cumpliendo otra. Se aplicaba por ejemplo cuando el esclavo cometía un delito, lo podía entregar haciendo el abandono noxal a la víctima o pagaba una indemnización. También el caso del aquél que tiene en su poder la cosa hipotecada, podía entregarla al acreedor o podía pagar la suma adeudada y no entregarla.

- El deudor quedaba liberado si una o ambas perecían por caso fortuito.
- Si la prestación comprometida se perdía por culpa del deudor, éste ofrecía el objeto subsistente.
- Si las dos se extinguían por culpa del deudor, el acreedor podía exigir la estimación de la comprometida *inobligatione*.
- Son indeterminadas, porque hay varias prestaciones, hasta que no se ejerza el derecho de elección no se podrá determinar cuál será.
- La prestación *in obligatione* si perece o se extingue por caso fortuito, extingue la obligación facultativa. En cambio en las alternativas deberá cumplirse con el objeto subsistente.

Obligaciones divisibles e indivisibles

Son divisibles cuando pueden ser cumplidas parcialmente, de manera fraccionada siendo cada parte similar a las otras partes como al todo. No se pierde la función económico- social del todo, cada parte

conserva la esencia del todo. Lo indivisible surge por exclusión del concepto dado. Es indivisible cuando el fraccionamiento implica la destrucción o extinción de la totalidad.

El problema no sería mayor cuando hay un solo deudor y un solo acreedor; Habría algunas cuestiones en el caso de que haya multiplicidad de sujetos activos o pasivos.

- El incumplimiento de la obligación indivisible hace que se indemnice, en ese caso se vuelve divisible porque se trata de sumas dinerarias.
- cada deudor solo responde de la propia culpa.

Obligaciones según los sujetos que intervienen

a) Obligaciones de sujetos determinados e indeterminados

En el primer caso se refiere a los sujetos que están individualizados desde el comienzo de la obligación hasta que finaliza ésta.

En el segundo caso se refiere a los cambios de sujetos que puede haber desde que nace la *obligatio* hasta que se extingue, ocurre por ejemplo en la cesión de créditos. Se califican a las obligaciones como ambulatorias o *propter rem* (protegidas por las *actiones in rem scriptae*). Puede ocurrir en el caso de delitos cometidos por el *filius*, al inicio de ésta situación no está definido quién es el que efectivamente va a responder, si éste o el *pater*. Otro caso es el del superficiario o enfiteuta que debe pagar el *solarium* o el canon adeudado, aún cuando fueran debidos por otras personas anteriores a éstos.

b) Multiplicidad de sujetos activos o pasivos: Obligaciones solidarias o correales

La solidaridad jurídica encuentra su origen en la solidaridad familiar de las épocas más antiguas cuando había que pagar el rescate de algún miembro del clan. La solidaridad luego podía provenir de una estipulación y luego de un contrato, por ejemplo la venta.

Caracterizadas bajo ésta denominación porque puede haber multiplicidad de sujetos que van a interactuar de distintas maneras:

1) La solidaridad del deudor podía encontrar dos aspectos, por un lado, que el deudor fuera único y el resto de los codeudores eran garantes. Por otro lado, que todos los deudores lo fueran por igual por tener un grado de interés en la concreción del acto jurídico y por eso asumieron el compromiso con el o los acreedores.

Cualquiera de las dos formas en que se diera, el acreedor sabía que tenía posibilidades de recibir su prestación de cualquiera de ellos y por el todo.

Puede haber por lo tanto, multiplicidad de deudores, ésta forma se denomina solidaridad pasiva puede tratarse de varios deudores con un acreedor, o con varios acreedores. El cumplimiento de la prestación por parte de uno solo de ellos alcanza al resto de los co-deudores, teniéndose por extinguida la prestación para todos por igual. Si bien hasta aquí, se extingue el vínculo jurídico con el/los acreedor/es, subsiste entre ellos la obligación de pagar la parte proporcional que les correspondía en el crédito al co-deudor que canceló la prestación. Si no lo hicieren voluntariamente podrán demandarse judicialmente su cumplimiento. También podían ser ejecutados todos patrimonialmente en caso de ser condenados en una sentencia. La mora los afectaba a todos por igual.

Al principio, a éstos sujetos que actuaban conjuntamente, sean deudores o acreedores, se los denominaba *socii*, y al que había hecho el pago, en caso de tratarse de los deudores se le otorgaba la *actio pro socio* con el fin de que le reclamara a los restantes codeudores el cumplimiento de la parte que les corresponde en la prestación. También podía ejercer la *actiemandati* contra su mandante reclamándole los gastos del negocio, en éste caso el pago de la deuda que él ya canceló.

El pago, la *novatio*, la *litis contestatio* realizada por uno de ellos beneficiaba al resto con la extinción de la *obligatio*.

2) Cuando hay multiplicidad de acreedores, se denomina solidaridad activa, puede tratarse de varios acreedores con un solo deudor o con varios deudores, ésta última se denomina solidaridad mixta. Opera de manera similar que en la de los deudores múltiples, el

acreedor que recibe el pago extingue el vínculo obligacional para todos por igual, pero subsiste la obligación para el que recibió el pago la obligación de pagarle a cada coacreedor la parte proporcional que les correspondía en el crédito, si no ocurriera de la manera descripta se demandará judicialmente su cobro.

La solidaridad no se presume. Surge de una disposición de última voluntad o de una convención, tanto la activa como la pasiva.

La correalidad pasiva puede surgir de la ley por ejemplo en el caso de que el *furtum* fuera cometido por varios ladrones, la *actio furti* (por el doble o *quadruplum* del valor de la cosa hurtada) contra el ladrón y la reipersecutoria para obtener un resarcimiento por el daño causado. La acción penal se ejerce por separado en contra de cada uno de los partícipes, mientras que la segunda se ejerce una sola vez contra cualquiera de ellos siendo la obligación de indemnizar de todos. Otro caso es el de los banqueros (*argentarii*) junto a sus socios tiene que responder solidariamente ante el reclamo de devolución del dinero por parte de los clientes.

Hay pluralidad de sujetos y una única prestación.

Gaius estableció como fuentes de las obligaciones, los contratos y los delitos, luego con el paso del tiempo fueron apareciendo otras figuras que, sin ser contratos o delitos, generaban obligaciones para quienes las llevaban a cabo, aparecieron así las varias figuras de causa, como los *quasi ex contractu* y los *quasi ex delicta*, conceptos ampliados por el Emperador Justiniano.

Los delitos

También llamados *maleficia*, eran conducta por las cuales se perjudicaba a un tercero, se les hacía un mal, un daño que según las transformaciones que devenían en la sociedad romana se iban modificando y adaptando a las nuevas posibilidades que aparecían.

Los hechos lícitos, tienen en contraposición los hechos ilícitos y dentro de ésta categoría aparecen los delitos.

Las figuras delictivas más antiguas las encontramos en la Ley de las XII Tablas, pero también las *Leges Regiae* hacían referencia a antiguas prohibiciones.

Los romanos conocieron dos grupos de delitos: los públicos: que defendían los intereses del Estado en lo referido al orden y a la seguridad públicas; no se analizarán en el presente libro. Y los de carácter privado referidos a los particulares, que sí serán vistos.

No tenían responsabilidad delictiva el infans, el loco, o por causa del error.

Los Delicta Privata

Son fuentes de obligaciones las que se analizarán a continuación.

El delito. Concepto

Al principio la noción de delito se relacionaba con el daño efectivamente causado y con la figura de su autor, allí radicaba el fundamento de la venganza. Con el paso del tiempo se empezaron a regular las figuras delictivas y sus penas.

Se trata de un hecho contrario al derecho que se sanciona o castiga con la pena.

En una sociedad que, primitivamente y desde la Ley de las XII Tablas se fue organizando social, política y religiosamente; se pensó en la necesidad de que el derecho objetivo regulara las figuras delictivas privadas. Fue un avance a las primitivas sociedades de la antigüedad que conocieron una norma jurídica que parecía inherente al hombre mismo: la ley del Talión, el sistema de venganza privada a los fines de promover una convivencia armónica y con las debidas regulaciones estatales, vino a suplantarla.

El furtum

Ésta figura delictiva encuentra su origen en la Ley de las XII tablas, siendo por lo tanto muy antigua.

Era desapoderar a otro de la cosa que le pertenecía, por lo que, el que desapoderaba no tenía ningún justificativo jurídico para hacerlo. El afectado o perjudicado si la tenía legalmente justificada y no había

por parte de éste consentimiento alguno para que otro se lleve algo que le pertenece.

En la definición aparece el elemento objetivo requerido para el delito: el desapoderamiento ilegítimo, mientras que la comisión del mismo debe estar complementado necesariamente por el elemento subjetivo: la intención – *animus furandi*- de desapoderar o consumir el hecho típico (el desapoderamiento); puede haber o no ventaja de carácter económica –*animus lucrandi*- .

Servio Sulpicio y Masurio Sabino fueron los que clasificaron al *furtum* en cuatro sub- clases

- a) *Furtum Manifestum*: Es cuando el ladrón es sorprendido cometiendo el delito o recién terminado de cometerlo (inmediato), también transportando las cosas producto de éste o cerca del lugar de acaecido el hecho.
- b) *Furtum nec manifestum*: No se dan ninguna de las condiciones anteriores, su definición se da por exclusión de los requisitos anteriores.

Las penas

El Estado ya tenía aquí una clara intervención en la regulación de las penas acorde a las figuras delictivas establecidas taxativamente, por ejemplo 25 ases al que había cortado un árbol, al usurero el doble de lo perjudicado a un tercero, al depositario que no devolvía lo dado en depósito, al vendedor que había vendido con engaño de las características del suelo vendido, por mencionar algunos casos. Aparece así el principio de equivalencia, la pena a acorde con la gravedad o no del delito. A diferencia de lo que ocurría con el Talión en que el castigo dependía del rencor o la liviandad de la víctima.

A partir de la Ley de las XII Tablas, la sanción penal deja de ser colectiva para ser ejercida solamente por el ofendido o sus herederos en los casos que correspondiera. El sistema del Talión permitía una especie de conciliación o acuerdo amigable. Antes de que los clanes fueran a la guerra, el jefe de familia entregaba al miembro de su gru-

po que había cometido la infracción, si había que pagar una multa lo hacía o entregaba al sujeto en abandono noxal.

Respecto a los demás ladrones flagrantes los decenviros establecieron que si eran libres se les azotase y entregase a quien hubiera sufrido del hurto (*addictus*); si fueran esclavos se le azotase y despenase por la roca Tarpeya (por disposiciones de la *Lex* de las XII Tablas); pero si fueran niños impúberes dispusieron que se les azotase, según el criterio del pretor, y que se reparase el daño causado).

Si por la noche alguien comentó un hurto y se le mató, se disponía que sea muerto conforme a derecho. Con el paso del tiempo se dejan de lado los castigos corporales y se castiga con el *quadruplum* del valor de la cosa.

Cuando el *furtum* era *nec manifestum* se castigaba con el doble del valor de la cosa.

- b) *Furtum conceptum*: Era cuando se encontraba la cosa sustraída en la casa de alguien, luego que ésta se revisaba por medio de una pesquisa solemne, por medio del ritual de litium y el platillo, la Ley de las XII Tablas refiere: *cum proletarii et adsidui et sanates et VADES et SUBVADES et XXV asses et taliones furtorumque quaestio CUM LANCE ETLICIO evanuerint, omnisque illa XII tabularum antiquitas – lege Aebutia lata consolita*, cuya traducción es: Actualmente los preceptos sobre los proletarios, hacendados, sanates, garantes y subgarantes, los veinticinco ases y los taliones, y la investigación de los robos mediante el rito del plato y del lizo atado a la cintura se han desvanecido, y toda aquella antigualla de las XII Tablas se habría olvidado cuando se aprobó la ley Ebucia, si no hubieran pervivido las causas centunvirales de las acciones de la ley.
- c) *Furtum oblatum*: Era cuando se encontraba la cosa robada en la casa de un tercero porque la había recibido del ladrón aún cuando obraba de buena fe.

La pena para el hurto descubierto y contra el que dio a otro el objeto robado es, según una ley de las XII Tablas, al triple, con un plato y un lizo atado a la cintura.

Si se reclama por un hurto que no fue flagrante - sanciónese el daño con el doble.

En relación a las penas se accionaba de la siguiente manera:

- 1) La *Actio reivindicatoria*: Era la más amplia de todas por los efectos que producía respecto del actor, ya que se trataba del dueño de la cosa
- 2) La *actio furti prohibiti*: quién no permitía la realización del registro domiciliario era sancionado con el *quadruplum* del valor de la cosa.
- 3) La *Actio Furti non exhibiti* operaba en contra del sujeto que tenía la cosa ajena consigo pero no la exhibía ante el requerimiento del magistrado. Con el paso del tiempo estas acciones fueron suprimidas por el Emperador Justiniano.
- 4) La *Condictio Furtiva*: A fines de la República, el carácter reipersecutorio en el *furtum* llegaba hasta la acción reivindicatoria que tenía el propietario de la cosa objeto de *furtum*; después se otorgó una acción personal llamada *condictio* furtiva, cuando la acción reivindicatoria por algún motivo no prosperaba que, luego se extendió a las cosas perdidas por caso fortuito según el valor más alto que tuviera la cosa después de acaecido el *furtum*. Estaba dirigida contra el ladrón y sus herederos con el objetivo de obtener la restitución de la cosa.

La rapina

Fue la sustracción violenta cometida por una banda de hombres, con el paso del tiempo se admitió que fuera cometido por un solo hombre, habiendo violencia con o sin armas, emerge de las disposiciones de la Ley de las XII Tablas.

- A) Si ocurría durante el día, si se defendía con armas, y pedía auxilio a gritos (si lo mataba era legítimo).

Las acciones que surgían eran las siguientes:

- 1) La *Actio vi bonorum raptorum*: Acción dirigida contra el ladrón que dentro del año en que había acaecido el hecho se quería llevar nuevamente la cosa, por el *quadruplum* del valor de la cosa, después de ese lapso era por el valor simple.

El *Damnum iniura datum*

Era una figura delictiva contemplada en la *Lex Aquilia*, un plebiscito que se presume fue dictado durante la tercera secesión de la plebe, antes del siglo VIII, también suele ubicársela en el siglo III a. C.

A través de ella se buscaba castigar el daño causado ilegítimamente o sin derecho, por medio de una *damnatio* contra el delincuente por la pena establecida.

Se encontraba regulado en dos capítulos; el I establecía que quién matare injustamente a un esclavo ajeno o cuadrúpedo que se halle comprendido en rebaño, sea condenado al delincuente a dar a su dueño, el máximo valor que la cosa hubiese tenido dentro de ese año.

Mientras que el capítulo III comprendía toda clase de daño sobre la cosa ajena como herir a los comprendidos en el capítulo I, a la quemadura, fractura, ruptura o derramamiento de una cosa ajena. La pena consistía en pagar al dueño el máximo valor que hubiere tenido la cosa 30 días anteriores a la causación del daño.

Si bien se requería el *corpore corpori datum* o relación de causalidad entre el sujeto que causa el daño y la cosa dañada, a todos aquellos objetos que no estaban contemplados en los capítulos I y III; como así también contra las personas libres que se encontraban bajo la *potestas* del *pater familias*.

Tanto la *Lex Aquilia*, como el *furtum* fueron acciones quiritarias, o sea propia de los ciudadanos romanos que, con el paso del tiempo se hicieron extensivas a los peregrinos a través de acciones ficticias en

las fórmulas, en la que se fingía una condición de ciudadanos que no tenían más que, a los efectos de la misma.

Iniuria

Antes de la *Lex Aebutia* (Siglo I a. C. que extinguió el sistema de las *Legis actionis* y apareció el procedimiento de las fórmulas), el pretor peregrino utilizaba la acción estimatoria en los delitos de injurias traducidos en violencia física de acuerdo a lo establecido por la *Lex* de las XII Tablas. La multa era solicitada solamente por el ofendido, lo que hace que el ejercicio de la acción fuera de carácter personalísimo. Si bien el demandado hacía una estimación de la multa en proporción al daño causado, luego el *iudex* hacía una tasación, excepto la injuria *atrox*, que era más grave, el monto era estimado por el pretor y el *iudex* no lo modificaba.

Con el paso del tiempo la injuria se hizo extensivo a otras conductas que eran lesivas: las verbales, los gestos; la manifestación ultrajante en contra de un tercero; también los golpes y ofensas dirigidas contra el esclavo como un ataque a su amo.

Comprendía diversas clases de acciones caracterizadas por el dolo que se traducían en las siguientes: ofender, difamar, insultar en forma oral o escrita a los *fili* y a la *uxor*, a un hombre libre, cuando se hacía en contra de un esclavo pero la injuria iba dirigida a su amo.

Comprendía a su vez las acciones traducidas en agresiones físicas a algunos de los mencionados anteriormente (excepto el esclavo), reflejado en la *Lex* de las XII Tablas cuando establecía que, si con la mano o con el bastón se le rompió un hueso a un hombre libre, se le palique la pena de trescientos ases; y si se tratara de un esclavo, de ciento cincuenta ases.

La Ley de las XII Tablas, en la Tabla VII establecía el castigo con la pena capital en los casos de los ultrajes de quién compusiera canciones dirigidas a difamar deshonar a otra persona, *-nostrae XII tabulae cum perpauca res capite sanxissent, in his hanc quoque sanciendam*

putaverunt: si quis occentavisset sive carmen condidisset, quod infamiam faceret flagitiumve alteri-.

Acciones que se ejercían

La *Actio Iniuriarum*

Si se trata de una injuria leve el monto es determinado por el ofendido en cambio si es grave, debe ser determinado por el pretor, como ya se explicara. La tabla VII establecía que si se causó una lesión menos grave, la pena será de veinticinco ases –*si iniuriam (alteri) faxsit, viginti quinque poenae sunt*- .

La *actio* podía ser ejercida no solo por el ofendido en vida, sino también por los herederos cuando se hubiese ofendido la memoria de un sujeto fallecido.

La *Dissimulatio*

Era el perdón del ofendido hacia el delincuente por el delito de injurias.

Responsabilidad del *Pater*

El *pater* debía responder por los daños causados por los que estaban bajo su potestas: Los esclavos y los filii. Con respecto a los primeros se dispuso que, si un esclavo cometió un *furtum* o causó un daño –*si servus furtum faxit noxiamve noxit*-, y con referencia a los delitos de los hijos de familia y de los esclavos, se daban las acciones noxales para que se permitiera al *pater* o al dueño o responsabilizarse pecuniariamente del delito o entregar al culpable. Las acciones noxales fueron establecidas por las leyes o por el edicto del pretor: por las leyes, como la de *furtum*, como lo fue la ley de las XII Tablas, –*Ex maleficio filiorum familias servorumque* – *noxales actiones proditae sunt, uti liceret patri dominove aut litis aestimationem sufferre aut*

noxae dedere. – Constitutae sunt autem noxales actiones aut legibus aut edicto praetoris: legibus, velut furti lege XII tabularum cet.-

Luego se consideró la posibilidad de que una acción injuriosa pudiera recaer sobre varias personas a la vez, había multiplicidad delictual. Por otro lado estaba la posibilidad de darle una defensa al que era demandado infundadamente por injurias otorgándosele el *judicium injuriae contrarium* por el cual eran condenados aquellos que habían realizado una acción por injurias y resultó que no había fundamentos para ello. Son condenados por difamación. Con respecto a la Ley Cornelia de *Iniuriis* (año 670 aproximadamente) prosperaba por medio de una *quaestio* perpetua, siendo las penas de carácter público, comprendía a los delitos que se basaban en la violencia corporal y a la violación de domicilio. En tiempos de Caracalla (siglo II d. C.), se consideraron públicos a demás de los mencionados el robo, la difamación y otras injurias, y la muerte del esclavo. Se podía optar por la persecución pública o privada.

Delitos pretorios

Se referían a los relacionados con el consentimiento, dado en los actos jurídicos o a sus consecuencias perjudiciales: La violencia (*metus* –miedo-), el dolo malo; fraude; obligaciones nacidas del depósito, del comodato, de la fiducia, de la prenda, del mandato, etc. Por lo menos hasta el siglo VII a. C.

El *metus* o miedo que provocaba la violencia, ya estaba contemplado en el Edicto del Pretor Octavio (año 670), era cualquier clase de acción física, moral, presente, provenientes de un sujeto, de carácter ilegítimos, contrarios a las leyes o a las costumbre, poniendo en peligro a otro, a tal punto que pudiera doblegar hasta al más fuerte. La *Actio quod metus* causa era concedida por el *quadruplum*, y dada contra el autor de la violencia. La acción prosperaba en contra de todos aquellos que se hubiesen beneficiado a causa de la violencia generada por el miedo, aún cuando no lo supiesen.

El *dolus malus*, parece el edito del Pretor *Aquilo Gallo* en el año 688 aproximadamente, se los relacionaba con los actos de simulación; eran artificios, artimañas, engaños, con el fin de que otro se equivoque y frustrarlo patrimonialmente. En tiempos de Paulo la cuestión debía ser evaluada por el *iudex*. Era una acción de carácter infamante y subsidiaria cuando no había otros medios jurídicos para reparar el daño causado.

El fraude creditorio, o referido a los acreedores era cuando el deudor de manera intencional se volvía insolvente o aumentaba la insolvencia. Era la acción pauliana o revocatoria, en contra del deudor y los terceros que hubieren colaborado con él maliciosamente en el fraude. Se trataba de una *actio* arbitraria. Prosperó en contra de los que habían realizado actos jurídicos a título gratuito por el/los autores y cómplices delictivos.

El fraude del liberto también fue castigado cuando se hacía para perjudicar a los herederos del patrono.

Las sanciones de los edictos eran acciones penales que se redactaban *in factum*. No se transmitían a los herederos y en algunos casos eran noxales.

En el dolo, el fraude y la violencia; parece que se ven más claramente la subjetividad o la intención de perjudicar o dañar, además de la conducta objetiva. Las acciones eran entabladas dentro del año después de pasado el año eran reemplazadas por acciones *in factum*, para pedir la reparación del daño causado o la devolución de lo obtenido por enriquecerse.

Los acusados de éstas figuras se defendían oponiendo exceptios como la *exceptio ob dolum*, la *exceptio quod metus* y la *exceptio ob fraudem creditorium*. Se evitaba la acción restituyendo o reparando el daño.

Las varias figuras de causa – *variae causarum figurae*–

Eran las obligaciones que surgían, no como consecuencias de un delito o contrato sino por situaciones que se parecían a los mencionados.

Se las trató de asimilar a los delitos por eso se les dio el nombre de *quasi ex delicta* y similares a los contratos, de allí surge el nombre de *quasi ex contractu*. La crítica que se le hace es que esas diversas situaciones que generaban un perjuicio y había que reparar, no se parecían en muchos casos ni a los delitos ni a los contratos. Algunas de las situaciones que son encuadradas en las varias figuras de causa quedaban sin efecto o devenían en abstracto cuando eran solucionadas por otras vías, por ejemplo, para el enriquecimiento sin causa se obligaba a devolver al perjudicado a través de condiciones, como las *condictiones certae pecuniae* y la *triticaria*. Se aplicaba la *condictio in certi* en el caso de que era necesaria una valuación judicial del enriquecimiento, para luego determinarse cuál era la *condictio* que debía aplicarse, así teníamos la *condictio indebiti* a los fines de recuperar la totalidad de lo dado de más por error. De ésta manera, quién había recibido de buena fe tenía que devolver antes de la *litis contestatio*. En cambio el de mala fe, además de devolver lo recibido indebidamente debe hacerse cargo de los perjuicios sufridos por la contraparte.

También había obligación de restituir por medio de la *condictio ob rem dati*, o *causa data causa non secuta* lo obtenido de otro que había sido con el fin de obtener un resultado al que nunca se llegó.

De carácter más general la *condictio sine causa* que se extendiera a los casos no contemplados expresamente.

La *condictio ob turpem u ob injustam causa* cuando el enriquecimiento fuera como consecuencia de actos contrarios a la moral y a la ley.

Los *Quasi ex delicta*

Eran aquéllas situaciones en las que se originaban un daño pero no estaban encuadradas en una figura delictiva, sin embargo fueron contempladas por la ley con el objeto de imponerse sanciones ante dichas eventualidades. A continuación pasan a detallarse.

Supuesto del Juez que hacía suya la causa

Se comienza a explicar ésta figura haciéndose referencia a que castiga con la pena de muerte al juez o al árbitro, nombrado legítimamente, convicto de haber aceptado dinero para dar sentencia. De ésta manera el *iudex* tomaba una decisión a favor de alguna de las partes, pero no porque le asistiera la razón sino porque había intereses que respaldaban ésta decisión, por lo tanto se trataba de una conducta premeditada que hacía con carácter doloso. Recordemos que el *iudex* antes de asumir sus funciones debía prestar juramento de actuar conforme a derecho, caso contrario debía apartarse del asunto.

El *Effusum et Deiectum*

Se trata de los casos en que alguien arroja (*effusum*) o tira (*deiectum*) objetos desde el interior de una casa y resulta dañado u tercero, el propietario o *habitor* deberá ser responsabilizado jurídicamente aún cuando no haya sido el que lo tiró o arrojó. Si el daño era sobre una cosa la acción era por el doble, en cambio cuando se trataba de la muerte de un hombre libre la pena era de un máximo de cincuenta sólidos de oro., por una herida la pena era de carácter indemnizatoria determinada por el *iudex*.

El *Possitum et Suspensum*

Es el caso de las cosas suspendidas (*suspensum*) o colgadas (*possitum*), como en el caso anterior pude ser el *habitor*, un propietario o la acción de los que están bajo sus *potestas* (responderá por la acción realizada por éstos) resarciendo el daño causado a terceros, la pena era de diez sólidos de oro.

El Supuesto del Dueño de un navío, posada o caballeriza

El propietario de los establecimientos mencionados cuando contrataba un dependiente se exigía de éstos una conducta acorde a sus

desempeños, pero en determinadas circunstancias podían causar un dalo a quienes concurrían a ellos. La reparación por parte del dueño se debía a la mala selección de los dependientes y la responsabilidad que emergía en consecuencia.

Quasi ex contractu

La negotiorum gestio

La gestión de negocios, era cuando alguien se hacía cargo de ejercer actos de administración en representación de un tercero sin que éste le diera su consentimiento. Aquí falta un elemento esencial para que fuera un contrato ya que está ausente el consentimiento. Esta es la principal diferencia con el mandato, en lo demás es muy similar en cuanto a los elementos que lo integran.

Esa representación en los negocios ajenos puede ser voluntaria o por error. En el período clásico surgieron dos acciones: la *actio negotiorum gestorum directa* era ejercida en contra del gestor con el fin de que responda en caso de causarle perjuicios al dueño del negocio, tampoco deje de realizar el actos de administración en perjuicio del segundo (administrado); también se le podía reclamar la rendición de cuentas.

Por otro lado, estaba la posibilidad de ejercer la *actio negotiorum gestorum contraria*, por parte del gestor para obtener la devolución a través de su reclamo de los gastos realizados en beneficio del negocio que es de otro. Ésta última prosperaba solo si el dueño del negocio había dado su consentimiento o sea ratificó el acto de administración realizado por el gestor; caso contrario los gastos son riesgos que corren por cuenta de éste.

La indivisión

Los casos de indivisión de la cosa común eran: la co- propiedad o condominio y la indivisión de la *hereditas*. En esos casos los condóminos tenían la *actio per iudicis postulationem*, se trataba de una de

las cinco acciones de la ley, encontrándose está entre las de carácter declarativo. Apareció luego la *actio communidivundo* o *actio in rem scripta* era oponible a los terceros que adquirirían la parte indivisa. La administración de la cosa indivisa les competía a todos por igual ya que era en beneficio colectivo, a todos beneficiaban las mejoras como podían perjudicarlos los gastos o pérdidas de alguna índole.

Tutela y curatela

En la tutela y en la curatela no había un convenio, pacto o contrato entre el pupilo con su tutor o curador respecto de la administración patrimonial, pero actuaban de manera similar como lo hacía un gestor de negocios.

El legado

Cuando se producía la muerte de una persona y dejaba un heredero, éste debía cumplir con la carga de entregar las cosas legadas a los legatarios. No era algo convenido expresamente entre el de *cujus* y el heredero, para obligarlo a cumplir pero era su obligación hacerlo. Tampoco había un acuerdo entre el legatario y el heredero.

El pago indebido –*solutio indebiti*–

A veces se daba el caso de aquellos que, por error pagaban algo que no debían pagar, porque la deuda no existía (*solutio indebiti*). Ello generaba en el que había recibido de buena fe, la obligación de restituir (*condictio indebiti*), porque no había una causa jurídica que justifique que siga reteniendo lo que había recibido, prospera en el caso de las obligaciones civiles, no así en las naturales.

Con el paso del tiempo aparece la noción del “enriquecimiento sin causa”, nadie podía tener una mejora patrimonial en perjuicio de un tercero y mucho menos si no había una causa jurídica que lo justifique.

El pretor había contemplado ciertos casos:

La *condictio indebiti*: Por medio de ella el sujeto pretende la devolución de lo que se hubiese pagado por error.

La *Condictio ob turpem causam* o *iniustam causam*: Por ella se reclamaba la devolución de una prestación que fuera realizada por causa ilícita o inmoral.

Condictio causa data causa non secuta: Cuando se realizaba una prestación teniendo en cuenta el cumplimiento futuro del resultado y éste no se obtenía, por medio de ella, se lograba la restitución de dicha prestación.

La *condictio sine causa*: Abarca todos los supuestos en los que no exista causa.

La *condictio furtiva*: Con ella se podía lograr que se devuelva la cosa hurtada.

La *condictio ex lege*: Cuando la ley reconoce una obligación sin indicar una acción precisa.

Formas de Garantizar las Obligaciones

El cumplimiento de una obligación se puede garantizar por medio de garantías personales como la fianza o de garantías reales como son la prenda y la hipoteca.

Fianza

Se trata de una *obligatio* de carácter accesorio, por la cual un sujeto va a sumir el compromiso de responder con lo propio por deudas de otros.

Clases de Fianzas

Las fianzas son obligaciones accesorias

- a) El *Fideipromissio*: Se hacía por medio de una *stipulatio* de carácter accesorio, podía haber varios fiadores. Según establecía la *Lex Furia* el plazo de duración era de dos años, cada uno respondía por lo que se había comprometido.

- b) Fideiussio: El fiador celebraba una stipulatio, servían para garantizar todo tipo de obligaciones. Como regla cada fiador responde solidariamente salvo que acuerden responder cada uno por su parte viril. Es transmisible a los herederos.

Los contratos

Lo que conocemos como contrato fue conocido por los romanos como convenciones que tenían los siguientes caracteres: un acuerdo de varios sujetos, en una misma manifestación de voluntad (univocidad del acto) de la que resulta una obligación, encuentra su protección en el derecho porque se puede demandar su cumplimiento en justicia (*actio*), por último ese acuerdo está previamente creado por el derecho.

Los Contratos Verbales

Se denominan de ésta manera porque se perfeccionan a través de la palabra. Ellos son:

- 1) La *Sponsio*
- 2) La *Stipulatio*
- 3) La *Dotis Dictio*
- 4) La *Promissio Iurata Liberti*

Los Contratos Literales

Denominados de ésta manera porque se perfeccionan a través de la escritura.

Ellos son:

- 1) La *Nomina transcriptitia*
- 2) Los *chirographae*
- 3) Los *syngraphae*

Los Contratos Consensuales

Denominados de ésta manera porque se perfeccionan por el consentimiento dado por las partes contratantes. Son los siguientes:

- 1) La Compraventa
- 2) La Locación
- 3) La sociedad
- 4) El mandato

Los Contratos Reales

Son los que se perfeccionan con la entrega de la cosa –*datio*–, la que da al contrato esa naturaleza. Son los siguientes:

- 1) El Mutuo
- 2) El Comodato
- 3) El depósito
- 4) La Prenda

Contratos

Evolución Histórica

En un principio, la palabra *contrahere* se aplica en un muy amplio sentido. A veces es sinónimo a *commitere* (cometer), otras veces es vocablo vecino a *constituere* (constituir). En cambio, *contractus* es mucho más tardío.

En el *ius civile*, la *conventio* o el *pactum* no generaban obligaciones jurídicas. Para que pueda surgir la obligatoriedad será necesario que esa convención este incorporada a un rito o solemnidad formal, que tiene la virtud de otorgarle la exigibilidad jurídica. Ello es lo que ocurre en el *nexum*, *sponsio* y *stipulatio*.

El pretor peregrino comenzó a reconocer, concediendo acciones, distintas formas contractuales del *ius gentium*, como los contractos reales y los consensuales.

En el período clásico, Gaius establece cuatro formas posibles de obligarse por *contractus*: que una obligación fuese contraída como consecuencia 1) de la entrega de una cosa (/re), 2) del pronunciamiento de ciertas palabras (*verbis*), 3) de ciertos registros por escrito (*litteris*), o 4) del solo consentimiento (*consensu*).

En la época clásica el elemento *consensus* después de las formas o de la entrega de las cosas. El jurista Pedio, citado por *Ulpiano*, establecía que todo contrato tiene una *conventio* (acuerdo de voluntades).

Los requisitos para que exista un contrato fueron

- 1) Que haya *consensus*.
- 2) Destinado a crear obligaciones.
- 3) Que tenga un nombre propio.
- 4) Que este protegido por una *actio*.

El nombre propio se refiere a que tiene que estar mencionados en la ley, o sea, tener existencia jurídica, el nombre aparecía en el Edicto del Pretor. La *actio* permitía ejercer el derecho de litigar, llevando una determinada cuestión a juicio.

Con el paso del tiempo apareció la doctrina de los contratos innominados *Labeón*, estableció que, la convención que estuviera incluida en los contratos reales o consensuales, siempre que no fuera ejecutada por una de las partes, daba a esta una *actio* especial contra la otra, acción que en los tiempos de *Justineano* es denominada *actio praescriptis verbis* (acción con palabras puestas al principio de la formula).

En el derecho imperial se admitirá que ciertos pactos gozarían de protección jurisdiccional, por ejemplo, en los casos de la donación y de la constitución de dote.

Clasificación

Las cuatro clases de contratos que señaló Gaius.

Contratos verbales

Son aquellos que se perfeccionan con el pronunciamiento de palabras solemnes.

La stipulatio

Es una forma de asumir una obligación entre dos o más personas, se realizaba oralmente y consistía en una pregunta y en una respuesta en concordancia con la pregunta formulada, podía hacerse en latín o en otra lengua extranjera, simbolizaba el consentimiento de los intervinientes el quiebre de la varilla o *stipz*, también podía hacerse dentro o fuera de la ciudad de Roma. No era necesario que sea formalizada solo por quirites, también podía ser hecha por extranjeros dentro de Roma y por quirites con extranjeros. Otro de los requisitos en la simultaneidad del acto, la respuesta no puede diferirse de la pregunta, tiene que haber entre una y otra un correlato necesario.

Si bien desde los comienzos se constituyó como un contrato *verbis* luego se permitió que fuera acompañado de un documento en el período posclásico se convierte en un contrato escrito.

De la *stipulatio* nace una acción, la *actio ex stipulatu*, la cual podía ser con formula certa, cuando el *quantum* de la obligación aparece claramente expresado, o con formula incerta, cuando no es así o la obligación es de hacer.

La *stipulatio* podía servir también para la aplicación de la llamada cláusula penal.

Adstipulatio

El *adstipulator* es un acreedor accesorio que tiene la confianza del acreedor principal y del cual este se sirve para cobrar el crédito.

Realizada la *stipulatio*, inmediatamente después se hace prometer la misma prestación por parte del deudor.

Le permitía al acreedor que tenía que ausentarse tener una persona de confianza que pudiera demandar al deudor.

Por ser accesoria, la obligación del adstipulator puede ser menor o igual a la del acreedor principal pero no mayor.

Dotis dictio

Se trata de una promesa solemne de dote que podía ser hecha por la mujer misma que iba a contraer matrimonio, o por su pater, o un deudor de ella, y estaba dirigida a especificar que bienes constituía la dote.

Se trataba de un contrato unilateral.

Se permitirá también efectuar la promesa de dote por medio de una stipulatio que será la promissio dotis.

Más tarde se hizo de la promesa de la dote un pacto legítimo, por lo que cayeron en desuso las formas anteriores.

Promissio iurata liberti

Se trataba de un contrato unilateral en que, bajo juramento el liberto se comprometía a efectuar determinadas obras a favor de su patrono.

Antes de manumitirlo, el dominus le hacía prestar al futuro liberto un juramento obligatorio, el cual era seguido, luego de la manumisión, por un segundo juramento, ya que se pensaba que el primero, prestado cuando aún era esclavo, no tenían completa exigibilidad. Esta forma de obligarse era también uno loquente. Para exigir su cumplimiento el patrono gozaba de una actio operarum.

Sponsio

Es un contrato que contaba con las formalidades mínimas para quedar perfeccionado, consistía simplemente en una pregunta y en una respuesta. Se respondía con el verbo que se utilizaba inicialmente para contratar: ejemplo: ¿spondes....? A lo que la contraparte respondía spondeo....; o ¿prometes...? Y la respuesta era “prometo”. En contraposición, si se quiere, se llevaba a cabo entre ciudadanos roma-

nos, dentro de la ciudad de Roma, para los extranjeros se reservaba la stipulatio. Se celebraba solo en latín.

Contratos literales

Los contratos literales son aquellos que se perfeccionan por medio de la escritura.

Nomina transcriptitia

Son los libros que tenía cada pater, llamado codex para llevar el estado patrimonial en dos libros: en uno se anotaban las operaciones patrimoniales familiares se llamaba adversaria, era una especie de libro diario llamado ephemeris en relación a anotaciones mensuales. Se dejaban constancia de dos clases de créditos: los nomina arcaria o movimientos de caja; y los nomina transcriptitia comprendían las dos formas posibles de contrato literal, se suponía la existencia previa de un crédito ya anotado en el codex, se hacía con el consentimiento del deudor; era reemplazado por otro en el que se asentaba un préstamo de dinero ficticio. En la transcriptio a re in personam, el acreedor era llevado lo que se debía por él en ese momento, podía tratarse de una venta, de un préstamo, etc. En la transcriptio a personam in personam, inscribía lo que le era debido por un tercero al pater. También se hacían anotaciones cuando las deudas eran canceladas pero lo escrito no le daba el carácter jurídico de una obligación extinguida.

No se tiene mucha certeza, ya que se cuenta con poca información. Se supone que al lado de la suma se anotaba el nombre del deudor, lo que le daba fuerza de ley a esa forma contractual. Este libro es solo un medio de prueba para las obligaciones pero fue empleado además para crearlas.

Las dos formas tenían en común que la anotación debía ser efectuada con consentimiento del deudor en el libro del acreedor, el cual podía darse verbalmente estando presente y debía anotarse la causa de la obligación.

El nomen trascripticium, conocido como a re in personam, servía para lograr los efectos de una novación objetiva.

El nomen trascripticium, conocido como a persona in personam, es utilizado para lograr los efectos de una novación subjetiva.

Chirographae y Singraphae

Hay una presunción asocia estas formas contractuales a los préstamos dinerarios.

El chirographum era un documento firmado solamente por el deudor y sellado con su anillo; aquel quedaba en poder del acreedor.

La syngrapha era un documento que se realizaba en dos ejemplares, firmados y sellados por el deudor y el acreedor, quedando uno en poder de cada uno de ellos.

Hoy lo podemos evaluar como un medio de prueba de la adquisición de una obligatio, pero en realidad en esa época, no surge claramente el sentido de la entrega de un documento a cada parte.

Lo que no se sabe con certeza era si servían como meros medios probatorios o si ambos tenían un valor abstracto constitutivo de obligaciones.

Contratos consensuales

Los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan por el mero consentimiento (consensus), no es necesario llevarlo a cabo el cumplimiento de otras formas.

Compra-venta

La compraventa (emptio venditio) es un contrato por medio del cual una persona llamada vendedor se obliga a transmitir la posesión de una cosa asegurando su pacífico goce a otra llamada comprador, que se compromete a abonar por ella un precio consistente en una suma de dinero.

Por la compraventa no se transmite la “propiedad” sino la “posesión”. Para adquirir el comprador el dominio de la cosa se hace necesaria la traditio de la cosa, respecto de la cual la compraventa funciona como iusta causa.

La compraventa, institución del ius gentium, con su consecuente traditio, reemplazó en el desarrollo histórico al ritual mancipatio, propia del ius civile.

Respecto al consentimiento, rige en Roma el principio de que nadie puede ser obligado a vender una cosa contra su voluntad. Solo en casos muy excepcionales puede haber obligación de vender una cosa. Por ejemplo, en virtud de una constitución de Antonio Pío respecto del esclavo maltratado por su dueño, o respecto de cereales, cuando una grave calamidad azotaba a Roma.

Las arras consisten en la entrega de un objeto o de una suma de dinero. El comprador solía entregar al vendedor, para dar firmeza al contrato, ya un anillo, ya una cantidad de dinero.

El objeto de una compraventa podía ser una res corporal como también una res incorporal.

El precio de la compraventa:

-debe ser dinero.

-Debe ser cierto. La certidumbre del precio radica en la determinación o posibilidad de determinación exacta del monto del precio.

-Debe ser verdadero, en el sentido de que no sea simulado, porque de lo contrario habría una donación.

-Se agregó luego que debe ser justo. Cada cosa tiene su justo precio, Justiniano estableció la rescisión del negocio en caso de lesión enorme, la cual ocurría cuando el precio era inferior a la mitad del justo valor de la cosa.

De la compraventa emanan las siguientes acciones.

- La actio empti, era ejercida por el comprador en contra del vendedor. Su propósito es lograr la posesión de la cosa vendida. El vendedor no está obligado, en principio, a transferirla el dominio

de la cosa, sino simplemente la posesión de la misma libre de toda injerencia de terceros.

El vendedor responde en caso de no poder entregar la cosa por haberse destruido, sea por su dolo o por su culpa. Solamente quedaría liberado por caso fortuito o fuerza mayor. En el siglo II d. C. era un medio de garantía por sí sola, el vendedor era obligado a dar las estipulaciones correspondientes. Contra aquellos que vendían esclavos o animales en los mercados públicos, aparecieron dos acciones, la primera servía para obligar al vendedor hasta dos meses después de la venta a dar las estipulaciones habituales de evicción. Después apareció la *actio redhibitoria*.

- La *actio venditi*, puede ejercerla el vendedor contra el comprador. Su propósito es exigir el pago del precio de la cosa vendida, los intereses u otros accesorios si los hubiere, de las ventas al contado, ya que era uno de los requisitos para que opere la transmisión de la propiedad. El comprador podía negarse al pago si la entrega de la cosa le era negada por el vendedor o había posibilidades fundadas de evicción. El comprador debe el precio aunque la cosa se haya destruido por caso fortuito o fuerza mayor antes de la entrega. Significa esto que los riesgos de la cosa son a cargo del comprador. El contrato quedó perfeccionado desde el momento mismo del consentimiento. Las únicas excepciones son el dolo y la culpa del vendedor, pues se entiende que éste tiene el deber de custodia de la cosa. También puede exigirle al comprador el pago de los gastos necesarios realizados para la conservación de la cosa vendida.

Para ser un contrato de buena fe, como elementos naturales de la compraventa aparecen: la evicción (garantía de los vicios jurídicos) y los vicios redhibitorios (garantía de los vicios materiales).

El vendedor no está obligado a transmitir al comprador la propiedad de la cosa. Basta que le entregue la posesión de la cosa libre de ocupantes y le asegure esa pacífica posesión. Esta situación se puede ver alterada cuando un tercero iniciare la acción reivindicatoria alegando que la cosa es en realidad suya.

En cuanto a los vicios redhibitorios el vendedor responde ante el comprador por los vicios que tenga la cosa y que él hubiera silenciado de manera dolosa; por ejemplo, se aseguro la existencia de ciertas cualidades esenciales que la cosa no tuvo.

La cosa vendida puede adolecer de ciertos vicios ocultos, el vendedor pudo no estar anoticiado de ello y por lo tanto no existir dolo. Para prevenirlos se utiliza la garantía de una *stipulatio*, comprometiéndose el vendedor a responder por ellos.

Los ediles curules van a establecer como elemento implícito en las compraventas, la responsabilidad del comprador por los vicios ocultos denominados también redhibitorios.

Se otorgan dos acciones, a elección del comprador:

La *actio redhibitoria*, cuyo objeto era lograr la resolución del negocio, de tal modo que se devolviera el precio pagado contra la entrega del objeto comprado. Sólo se podía ejercitar dentro de los seis meses siguientes al negocio, la resolución dependía del *arbitratu* del *iudex* a la que se sumaba una condena por un monto similar al precio. Si el vendedor no restituía la condena era por el doble del precio más los accesorios.

La *actio quanti minoris* o *estimatoria* cuyo objetivo lo habilitaba al comprador durante el lapso de un año a pedir una minoración del precio pagado. Lo resolvía el *iudex* según la gravedad del vicio.

A la compraventa se le suelen agregar ciertos pactos tendientes a modificar los efectos normales del contrato:

La *lex commissoria*. Se celebra el negocio, pero se lo deja subordinado a una condición resolutoria: que el comprador pague el precio dentro de un plazo determinado. Si aun no ocurriere, deberá restituirse la cosa con los frutos percibidos.

El *pactum displicentiae*. Se celebra el negocio, pero se lo deja subordinado a la condición resolutoria de que, si la cosa no resulta del agrado del comprador dentro de un plazo determinado, entonces deja de haber negocio. También podía ser establecida como condi-

ción suspensiva, de tal modo que el negocio sólo se perfeccionaba cuando el comprador manifestaba su interés en un plazo dado.

In diem addictio. El vendedor se reservara el derecho de rescindir la compraventa si dentro de un plazo determinado aparece un interesado que le ofrezca un mejor precio.

El pacto de retroventa. Por medio de él el vendedor se reserva la facultad de readquirir la casa dentro de un cierto plazo, mediante la restitución del precio pagado.

El pactum de retroemendo. Es el pacto por medio del cual el comprador puede obligar al vendedor a que le readquiera la cosa vendida, luego de transcurrido un plazo, por el mismo precio.

Locación –locatio-

Concepto

En la locación una persona llamada locator se obliga a proporcionar a otra llamada conductor el uso o el uso y disfrute de una cosa determinada (locatio rei), o la prestación de ciertos servicios mediante (locatio operum) el pago de un precio denominado generalmente alquiler. El conductor también podía comprometerse a trabajar sobre una cosa que le confiaba el locator, pagándole una merces (suma de dinero), ésta última era la locatio operis fasciendi.

En la locación de cosas el locator se compromete a entregar a la otra parte la cosa locada, corriendo a su cargo las reparaciones que sea necesario hacer en la misma para un uso adecuado.

El conductor se compromete a pagar el precio convenido, debiendo usar de la cosa conforme al destino de la misma y devolverla una vez concluido el arriendo.

La situación del locario resulta, frente a terceros, bastante precaria, ya que no es considerado un poseedor, sino un mero tenedor de la cosa, por lo que carece de los interdictos.

Se distingue entre la locación de servicios y la locación de obra.

En la locación de servicio, las partes han tenido en cuenta la prestación, la actividad, el obrar del locator, se calcula en espacios regulares de tiempo: se contrata a un albañil la construcción de un muro, por una cantidad pre establecida.

En la locación de obra se contrata en función de la prestación del opus, es decir la obra, el resultado del trabajo de locator, con prescindencia del tiempo que insuma su realización: se le encarga al albañil la construcción de un muro determinado y se le paga tanto por la realización de ese muro o se le paga por la construcción de cada metro cuadrado de muro. Es decir, se le paga por los resultados y no por la prestación.

Es presupuesto que la obra sea realizada con materiales del locatario.

Se entendió que el riesgo de la cosa corría a cargo del locator hasta tanto se entregase la obra o ésta fuese aprobada, salvo el supuesto de fuerza mayor.

De la locación surge dos acciones: la *actio locati* para sancionar a los conductores o locatarios-, y la *actio conducti* que sancionaba al locator. Ambas son *bonae fidei*.

El locator *rei* tenía la obligación de garantizar el uso y goce pacífico de la cosa en caso de que aparecieran vicios. El locator *operarum* debía hacer el trabajo convenido.

El locatario *rei* tenía la obligación de pagar el precio del alquiler.

Como regla general los locadores soportaban los riesgos, excepcionalmente el conductor *operis facienti* que sí asumía los riesgos.

La *Lex Rodhia de Jactu*, en caso de las pérdidas ocurridas en el mar, era soportada proporcionalmente entre los propietarios de las cosas que se habían salvado.

Los arrendamientos rurales duraban cinco años. La de inmuebles se prorrogaba de año a año por *tácita reconducción*.

Se podía pedir la resolución por ejercicio abusivo del disfrute o uso, había roturas o deterioros sin las reparaciones correspondientes, por falta del pago del alquiler durante dos años, o en el caso de la

necesidad del locador de habitar su casa, por mencionar algunas de las más comunes.

Sociedad

La sociedad era un contrato en el que dos o varias personas se obligaban a poner en común bienes o de trabajo para obtener una ventaja o provecho también en común.

Para su constitución se requería de un elemento subjetivo que, era la intención de los socios se basaba en la *affectus societatis*, determina la esencia de ésta clase de contratos de sociedad.

Había dos que eran a título universal: la *societas totorum bonorum*, o sociedad de los bienes que pertenecían a los co herederos, *consortium*; por otro lado la *societas quaestuum* realizada entre manumitidos referidos a los bienes que obtenían por su actividad.

Se ponía fin a los patrimonios en común de varias personas por medio de la *actio familiae erciscundae* (división entre los co- herederos); la *iudicis postulationem arbitri* para la división de la cosa en común a través de la *actio communi dividundo* entre los co- propietarios o condóminos.

Había sociedades a título particular: la *societas unius rei*, tenía por objeto una o varias cosas determinadas; y la *societas alicuius negotiationis*, en la cual los aportes se realizan para una sola operación o una serie determinada de negocios, como por ejemplo, para el comerciantes de esclavos, de agricultores, de obreros, etc.

La sociedad se constituye por el libre consentimiento de sus miembros, bastaba que uno solo de los socios decidiera retirarse para que el contrato quedara concluido.

Había dos figuras de sociedad: la *societas omnium bonorum*, que se caracterizaba por el hecho de que en ella los socios aportaban en común la totalidad de sus patrimonios,

Respecto de las ganancias y de las pérdidas, si nada se convino se entiende que son siempre por partes iguales. Si se conviene cómo será

el reparto de ambas, el derecho clásico, por regla general, permitirá una relativa desigualdad entre ambas.

Si se determinaron las proporciones de las ganancias, pero no las de las pérdidas, o viceversa, se debe entender que lo establecido para un caso debe regir para el otro.

Una vez extinguida la sociedad, por la voluntad de todos, o la de uno solo, o la muerte de un socio, o haber concluido el plazo convenido, por capitis deminutio, por caer en bancarrota, por haberse realizado el negocio para el cual se había creado, por pérdida del capital social.

Cada uno de los socios tiene la actio pro socio. Servía para establecer las ganancias y las pérdidas que le correspondían a cada uno. Si había que dividir una cosa en especie se utilizaba la actio communi dividendo.

También podía responsabilizar a otro socio por dolo o culpa en el ejercicio de las reclamaciones societarias. En este caso tiene un carácter infamante.

Mandato

El mandato es el contrato en cuál una persona: el mandante; confía la realización de uno o varios negocios tengan o no carácter jurídico, asumiendo los riegos, a otra; el mandatario y debiendo rendir cuenta por ellos.

Es un contrato consensual, pero bilateral imperfecto; genera obligaciones solo para el mandatario.

Debe el mandatario encargarse de llevar a cabo la administración de todo patrimonio, mandato general, o de un negocio determinado, mandato especial.

El objeto encargado debe ser un simple hecho, o un acto o un negocio jurídico, siempre que sea lícito y no contrario a las costumbres.

El mandato debe ser siempre en interés del propio mandante o de un tercero.

El mandatario está obligado a cumplir el encargo del mandante, respetando las instrucciones recibidas o las que rigen en general de acuerdo con la naturaleza del negocio.

El mandato concluye:

- Por haberse realizado el negocio encomendado.
- Por muerte de alguna de las partes.
- Por la voluntad concorde de las partes y por la voluntad de una de ellas, pudiendo darse el caso de la revocación por parte del mandante o el de la renuncia por parte del mandatario.

En el caso de la revocatio, ésta solo produce efectos desde el momento en que la conoced el mandatario.

En el caso de la renunciatio, el mandatario responde de los perjuicios ocasionados en caso de producirse ésta en forma intempestiva.

En caso de muerte del demandado, el mandatario puede accionar contra los herederos del mandante si actuó ignorando su muerte.

Las acciones nacidas del mandato son las actio mandati directa la ejerce el mandante para exigir el cumplimiento del mandato, y todo lo que el virtud de él hubiese recibido el mandatario con motivo del encarga. Expresado de otra manera se le pide la rendición de cuentas al mandatario por la falta de ejecución total o parcial.

La actio mandati contraria corresponde, al mandatario contra el mandante para reclamar que se le abonen los gastos realizados en el cumplimiento del mandato o los perjuicios ocasionados durante el cometido. Se le exigía al mandante que asumiera la responsabilidad de las obligaciones contraídas por el mandatario como consecuencia del mandato.

Contratos reales

Los contratos reales son aquellos que se perfeccionan por la entrega de la cosa (res).

Mutuo – mutuum-

Ésta forma contractual al principio servía para favorecer o satisfacer las necesidades del prestatario. Los préstamos de dinero o de cosa fungible llevaban a que existieran riesgos, de que no se devolvieran dichos dineros, en esos casos se cobraban además intereses.

Los intereses se acordaban por medio de una stipulatio usurarum o estipulatio de usura, al vencimiento de cada mes se ejercía la actio de kalendarii. También podía celebrarse una stipulatio sortis et usurarum: se incluían la devolución del capital de origen y los intereses para formalizar no solo en sentido jurídico sino práctico la ausencia de usura.

EL máximo monto de la tasa de interés fue fijado por la unciarum foenus de la Ley de las XII Tablas y la Ley Diulia Moenia del año 397 A. c. equivalente a un 8 1/3 por cada 100 ases y por año, pero también se cree que el monto corresponde al tiempo que duraba el préstamo, o sea un mes, siendo el interés de usura al llegar al 100%, es más probable que fuera ésta última y no la primera por ser bajo el monto.

Si bien existió la Ley Genucia (año 412 d.C.) no se aplicó durante bastante tiempo, ella prohibía los préstamos a tasas de interés. Durante el período republicano se aplicó una tasa del 12 por ciento.

El faenerator (usurero) era castigado con una pena de multa por el quadruplum, después de la Ley Marcia fue castigado con la manus iniectio. Las constituciones establecieron dejar sin efecto los intereses cuando iguales al capital de origen. Por le senadoconsulto Macedoniano, de tiempos de Vespasiano se le otorgaba al paterfamilias y al filius una exceptio para defenderse de reclamos dinerarios realizados al último.

En tiempos de Caracalla, solo los préstamos que se hacían por escrito, al tener un valor probatorio eran los que valían, no obstante que, en el caso de ser llevado a juicio podía ser desvirtuado por otras pruebas. El plazo máximo para discutir en juicio el escrito era de un año y después se extendió a cinco, luego prescribía.

El *nauticum foenus* referido a la *pecunia trajecticia* o sea el dinero prestado para el comercio por mar, si se perdían las mercaderías en un naufragio, el riesgo era asumido por el prestamista, pero mientras ello no pasara podía pedir un interés superior a lo establecido por las normas.

Por ese motivo era un préstamo de consumo y con desplazamiento del valor. Por él se transmitía la propiedad de una cosa del *tradens*, a otra, llamada *accipiens* cierta cantidad de cosas que podían ser pesadas, contadas o medidas, (fungibles); por las que el adquirente tenía la obligación de devolver cosas de igual naturaleza y cantidad. Intervienen dos sujetos: el mutuante, es el que entrega y la que recibe el mutuario.

A veces no era necesaria la *datio* (entrega en propiedad de la cosa), permitiéndose que si una persona, por otra causa, tenía una suma de dinero de otro, y esta lo autorizaba a retenerla y gastarla, era como si hubiese habido un mutuo.

El mutuante tiene, para reclamar la devolución de lo prestado, la *actio certae pecuniae*, si se trataba de una suma de dinero; o la *condictio certae rei*, si se trataba de cosas fungibles.

Este contrato de mutuo estaba prohibido para que por el se prestara dinero a un *filifamilias*.

En la época más antigua se aplicaba la *manus iniectio*, después se aplicó la *legis actio per conditionem* para cuestiones menos graves.

Comodato

Es la entrega de una cosa a otro para que la use de manera gratuita. Intervienen dos sujetos: el comodante: es el que entrega y el comodatario que se sirve de ella. Éste último la tiene que restituir al cabo de un lapso acordado previamente. Si éste no existiera la cosa debe restituirse al primer requerimiento de la contraparte.

Se trata acá de un préstamo de uso. A diferencia del mutuo, el mandante no adquiere la propiedad ni tampoco la posesión, no tiene los interdictos posesorios, sino la mera tenencia de la cosa.

Pueden ser objeto de este contrato las cosas muebles o inmuebles, debiendo en principio ser no consumibles.

El comodatario debe usar la cosa de un modo normal o teniendo en cuenta lo convenido. Si hace un uso distinto al convenido puede caer en el *furtum usus*.

Del comodato nace para el comodante la *actio comodati* para recuperar la cosa prestada.

El comodatario gozaba del *contrarium commodati iudicium*, por medio del cual podía reclamar del comandante el pago de gastos realizados por él para mantener la cosa, así como perjuicios sufridos por haberse entregado una cosa defectuosa.

Depósito

Es un contrato en el que intervienen dos partes: el depositante, entrega a otra una cosa mueble confiándole la guarda a otro que es el depositario, éste asume la obligación de devolverla al primer requerimiento. Es la definición del depósito regular.

El depositario es un mero tenedor de la cosa. No puede usarla, debiendo custodiarla hasta que se la reclame el depositante; o si medió un plazo, al vencer éste.

En principio era un contrato gratuito, aunque en la época *justiniane* se permitió la retribución de una mínima suma.

Hubo varias figuras de depósito:

-Depósito regular.

-Depósito irregular, en la época posclásica se admitió el depósito del dinero u otros objetos fungibles, el depositario podía cobrar intereses, por eso se lo asimiló a un préstamo o mutuo, dado que éste podía consumirlo y restituir otro objeto igual por tratarse de cosas fungibles.

-Depósito necesario o miserable, es el que tenía lugar en situaciones no comunes como, incendios, terremotos, naufragios, el depositante no tenía opciones para elegir a quién depositarle la cosa, de allí surge su nombre.

En caso de que hubiera conflictos, se resolvía de la siguiente manera, si hubo dolo por parte del depositario, este debía responder por el doble. Podía ejercerse en contra de sus herederos, quienes si cometieron también dolo responden por el doble del valor de la cosa; si solo hubo dolo del causante, por el valor simple.

Secuestro

Es cuando se entrega la cosa litigiosa a una de las partes o a un tercero para que la administre. El secuestrario tiene a su favor los interdictos en caso de que alguien lo perturbe o le arrebatase la cosa. Al que le corresponda judicialmente la cosa y no se la restituyera tiene contra el secuestrario la acción de secuestro.

El depositante tiene la actio depositi para la restitución de la cosa, la cual tiene carácter infamante.

El depositario tiene un *contrarium depositi iudicium* para obtener lo que pagó para mantener la cosa y eventualmente por los daños sufridos o vicios que tuviera la misma.

Prenda – pignus-

Era la entrega de una cosa en posesión al acreedor para seguridad de su crédito, y se comprometía a devolverlo (acreedor) una vez pagado.

Si se pagaba la deuda, el deudor tenía la actio pignoratitia para recobrar la cosa preñada. Si no se pagaba dependía de la existencia en este contrato del *pactum commisorium*, en el que el acreedor queda como propietario de la cosa. También podía acordarse el *pactum vendendi*, por el cual el acreedor no se puede quedar con la cosa; debe subastarla y devolver el *superfluum*, lo que sobra una vez satisfecha la deuda, al deudor ese excedente, si no lo hace puede ser demandado por la actio pignoratitia.

El acreedor estaba protegido por los interdictos aún en contra del deudor. Vencida la obligación se permitía que el acreedor venda la cosa dada en prenda para cobrarse su deuda.

Los contratos innominados

En estos casos existían regularmente una prestación y una contraprestación. Si una de ellas había transferido una cosa y no obtenía la contraprestación, se le admitía la posibilidad de interponer la conditio, para que pudiera pedir la devolución.

Este remedio podía utilizarse en el supuesto de que se hubiera entregado una cosa, pero resultaba inútil si la prestación había consistido en una facere (hacer), que no se puede repetir.

La escuela romano- bizantina terminara de estructurar estas figuras mediante la concesión de una acción genérica denominada actio praescriptio verbis.

La denominación de esta actio se debe a la colocación de palabras opuestas al comienzo de la formula (praescriptio).

Estos contratos se consideran siempre “contratos reales” porque en ellos la prestación debía preceder siempre a la contraprestación reclamada.

Se construyeron cuatro figuras generales:

- a) “doy para que des”
- b) “doy para que hagas”
- c) “hago para que des”
- d) “hago para que hagas”

Los principales contratos innominados son:

Permuta (doy para que des)

Por ella una de las partes entrega a la otra la propiedad de una cosa a cambio de una prestación similar de la parte contraria. Es del genero do ut des.

Aestimatum

Una persona entrega a otra una cosa estimada en un valor determinado. Esta la puede vender, incluso a un precio superior, solo le será requerido lo estimado, el excedente lo retendrá para sí. Si luego de un cierto tiempo no la vendió, deberá devolverla.

Precarium

Es cuando se entrega en forma gratuita una cosa a un tercero para que la use. Debe ser entregada cuando el primero la pida.

La donación con cargo

Cuando un sujeto recibe una cosa, se le puede imponer al beneficiado una obligación a cumplir llamada cargo o modo.

La transactio

Es un acuerdo celebrado entre las partes para poder cerrar un proceso judicial o no llegar a él y resolver la cuestión extrajudicialmente.

Las convenciones

Eran compromisos recíprocos de las partes con el fin de proporcionarse distintas prestaciones y subsistían como pactos.

Si una de las partes cumplía con su parte y la otra no, para evitar un enriquecimiento sin causa, se ejercía la *condictio ob rem dati* o *causa data, causa non secuta*. En el caso de que la prestación fuera un hecho y no una cosa se otorgaban acciones *in factum*. También se otorgaba la *actio doli mali*.

Los pactos adjuntos a un contrato y los pactos pretorios

A partir del siglo VII se desarrollaron lo que una doctrina moderna denominó los *pacta adjecta*, son los pactos accesorios a un contrato. El edicto prevé las sanciones de los pactos que no estaban contemplados en el derecho civil.

El pretor otorgó una *exceptio pacti*, para quién probase que el pacto había finalizado o disminuido su obligación.

Después aparece el pacto in continenti en los contratos de buena fe, eran solo cláusulas, por ese motivo cayó en desuso la exceptio pacti. En cambio se aplicó ésta última para los pactos ex intervallo en los contratos de buena fe, se pedía para los de derecho estricto en los casos de disminución de la obligación.

En el pacto de juramento – pactum de jurejurando-

Por él dos litigantes acordaban atenerse para poner fin al litigio al juramento de uno de ellos. Cuando el juramento voluntario era prestado por el acreedor nacía una acción in factum, y si era prestado el juramento por el deudor se le otorgaba una exceptio jurisjurandi, contra la persecución del primero.

El receptum argentarii

Era una operación por la cual un banquero se comprometía aunque fuese por error a pagar la deuda de otro porque se hacía una combinación con la garantía. Los banqueros no solo hacían operaciones con dinero sino con otra clase de objetos.

El receptum nautarum, cauponum, stabulariorum; en las que los marineros, taberneros y hosteleros, eran responsables salvo casos de fuerza mayor de la destrucción, pérdida o deterioro de los objetos de los viajeros que les fueron confiados.

Pactum de pecunia constituta

Era el compromiso asumido por el deudor a cambio de un plazo de gracia, para entregar en una fecha fijada una suma de dinero o cierta cantidad de géneros. Al principio tuvo una acción penal y anual. Después se fue aplicando la actio certae pecuniae creditae; pero con elevación del total de la sponsio de la que se deducía la mitad del valor del litigio. En la época clásica se aplicó la pecunia constituta se hacía comprometer al deudor con un nuevo acreedor o se unía al crédito una nueva caución.

Capacidad y consentimiento de los contratantes

La cuestión del consentimiento pudo ser analizada desde varios puntos de vista.

Los *alieni iuris* si bien no tenían capacidad jurídica para los actos negociales, cuando tuvieron la posibilidad de administrar sus peculios se podían celebrar éstos con los *alieni iuris*. El problema podía radicar en cuáles eran los límites en su capacidad de administrar lo propio. Su consentimiento obraba a través de sus representantes; los tutores, ya sea que el acto jurídico sea llevado a cabo por el tutor o por el pupilo con la *auctoritas* de éste.

Se tenía presente el consentimiento al principio solo en los contratos verbales, en donde quedaba expresado por la pregunta y por las respuestas dadas por las partes. En apariencia no habría mayores cuestionamientos pero después se planteó la posibilidad de pensar si esa voluntad fue libre o se logró a través del fraude, el dolo o la violencia del miedo. En los casos que se planteaban éstas cuestiones existían

las acciones de dolo, la *quod metus causa*, con sus correspondientes excepciones para los demandados.

Otro de los aspectos que pudieron influir en limitar la libre voluntad y por ende, el libre consentimiento dado en un acto negocial fue el error acerca de algo específicamente sobre la naturaleza del contrato. Éste problema no existía en los contratos cuyo cumplimiento de las formas no dejaban lugar a dudas del consentimiento prestado en ellos, le daba más fuerza el cumplimiento de los requisitos formales y era más difícil probar si se había hecho conseguido a través de algún vicio (error, dolo, violencia, fraude). En ésta perspectiva no entre en juego la causa, ya que las formalidades cumplidas hacían nacer a la vida jurídica al acto. Pero era requisito de todo contrato tanto formal como no formal tener una causa lícita, si no se cumplía con esto último el negocio o acto era ilícito. La consecuencia era la nulidad.

La palabra pacto tuvo diferentes acepciones según su evolución histórica.

Sin embargo hubo algunos pactos que merecieron la protección por parte del pretor. Son los conocidos como *pacta praetoria*. El acuerdo de voluntades concluido entre dos o más personas sin formalidad alguna, que no estaba incluido dentro de las distintas categorías de contratos por el Derecho Romano, ha sido designado con el término general de pacto.

El simple pacto o pacto desnudo no engendraba obligaciones civilmente exigibles por carecer de acción. No obstante, la legislación romana fue concediendo fuerza obligatoria a ciertos pactos por la importancia cada vez más creciente de estos acuerdos de voluntades de tan fácil concertación, obrando en este sentido la jurisprudencia, el derecho pretoriano y la legislación imperial. Los pactos dotados de exigibilidad han sido llamados por los comentaristas pactos vestidos.

Los pactos vestidos aparecen así cuando la jurisprudencia decidió dar validez a los acuerdos celebrados entre particulares, con la condición de que no fueran contrarios a las leyes ni ocultaren una intención fraudulenta y siempre que estuvieran agregados a un contrato de

buena fe como cláusula adicional para modificar los efectos normales del mismo, acordándoles igual validez jurídica que la del contrato al cual estaban adheridos. Por este conducto nacieron los llamados pactos adjuntos o *pacta adiecta*, protegidos por la *exceptio pacti conventi* y también por la *actio* emergente del contrato principal. En su hacer jurisdiccional el pretor, poniendo en ejercicio sus facultades de *dare et denegare actinem*, permitió exigir judicialmente lo que las partes hubieran convenido por pacto en determinadas relaciones. De esta forma fueron creados los llamados pactos pretorios o *pacta praetoriae*. Siguiendo esta evolución, el derecho imperial contempló los negocios que se concertaban por pacto y que hasta entonces habían estado desprovistos de tutela procesal, dándoseles fuerza obligatoria por medio de constituciones imperiales y acordándoles para su ejercicio una acción especial, la *condictio ex lege*. De esta manera aparecieron los llamados pactos legítimos o *pacta legitima*.

Pacta Adiecta

Las convenciones accesorias agregadas a un contrato de buena fe con el fin de modificar sus efectos naturales, constituían los *pacta bonae fidei contractui adiecta*, más comúnmente llamados *pacta adiecta*. Estos acuerdos de voluntades, al estar adicionados a un contrato nominado tuvieron la fuerza obligatoria que del mismo derivaba, siempre que no alteraran sus elementos esenciales, por conducto de la acción que protegía el contrato principal. Los pactos adjuntos, que podían servir para agravar las obligaciones de una de las partes (*ad augendam obligationem*) o para disminuirlas (*ad minuenda obligationem*), fueron de dos clases, *incontinenti*, cuando se celebraban simultáneamente y *ex intervallo*, cuando su concertación era posterior al mismo.

En los contratos de buena fe, los pactos *in continenti* se obraban como pactos vestidos porque daban lugar a obligaciones civiles por estar agregados a un contrato